EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ABIT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E CONFECÇÃO, entidade de classe de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 62.673.454/0001-80, e com sede na Rua Marquês de Itu, 968, Vila Buarque, São Paulo/SP. Cep 01223-000, neste ato representada por seus representantes estatutários, vem respeitosamente à presença de V. Exa., com fundamento na prerrogativa que lhe é assegurada pelo artigo 103, inciso V, da Constituição Federal de 1988, e artigo 102, inciso I, alíneas "a" e "p", da mesma Carta Magna (cujo procedimento é regulamentado pela Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999), ajuizar

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de medida cautelar

em face do item 14.05 da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar n. 116/2003, na redação que lhe foi dada pelo art. 3º da Lei Complementar 157/2016, e o faz pelas razões de fato e de direito a seguir declinados:

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA

Conforme atesta seu estatuto social, a Autora é entidade associativa formada para defender os interesses das indústrias pertencentes ao setor têxtil e confecções, razão pela qual possui legitimidade ativa para a propositura da presente ADI, nos termos do artigo 103, IX da Constituição Federal.

II – DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

A pretensão da Autora é obtenção de uma decisão colegiada que, em sede de controle abstrato das normas, interprete conforme a Constituição Federal o item 14.05 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, na redação que lhe foi dada pela Lei Complementar n. 157/2016, **e declare que os serviços de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, quando inseridos no contexto de um ciclo produtivo, estão sujeitos à incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)**.

Ao mesmo tempo, e por mera extensão lógica, a Autora também pretende a declaração de inconstitucionalidade da interpretação do referido item 14.05 da Lista Anexa de Serviços como base legal de incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS).

O pleito se justifica tanto do ponto de vista comercial quanto, sobretudo, do jurídico. Em relação ao primeiro quesito, é evidente que a incidência do ISS sobre os serviços de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento realizados sob a forma de encomenda, *dada a sua natureza cumulativa*, trará enormes prejuízos às empresas da indústria têxtil. Quanto ao segundo, a admissão da sujeição destas atividades ao imposto estadual viola, a um só tempo, diversos preceitos constitucionais, como adiante se verá, tais como a não-cumulatividade, isonomia, e competência tributária.

Senão vejamos.

III – DO DIREITO

Quem milita no direito tributário nos últimos, digamos, 40 anos (como os signatários desta peça e provavelmente os senhores julgadores), certamente já se deparou com três profundas alterações na legislação de regência do ISS.

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o imposto era disciplinado pelo Decreto-Lei n. 406/1968, que, originalmente, disciplinava os – eternos – conflitos de competência entre o antigo ICM e do ISS. Na época, as atividades têxteis eram verbetizados no item 72 da Lista da Serviços, assim redigida:

> *72. Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de* ***objetos não destinados à industrialização ou comercialização****;*

Veja-se que, já no princípio do regramento do tema, o legislador demonstrou sua preocupação em respeitar, no plano infraconstitucional, as respectivas competências tributárias estaduais e municipais, atribuindo, nos casos de serviços que envolvessem o fornecimento de mercadorias ou que estivessem inseridos num âmbito produtivo, a Cesar apenas o que efetivamente fosse de Cesar.

Isso explica o trecho destacado em negrito, o qual, no fundo, não deixa de ser a explicitação advinda da Constituição Federal (não a atual, mas a de 1946), de que, embora tangenciem em diversos pontos, os serviços e a circulação de mercadorias habitam diferentes zonas tributárias.

Já na vigência da Constituição Federal de 1988, o ISS sofreu a maior alteração legislativa da sua história, que se materializou na forma da Lei Complementar n. 116/2003. Se a intenção do legislador era mirar na solução definitiva das eternas celeumas do imposto (vale dizer, conflito de competência intermunicipal, responsabilidade tributária etc.), ele acertou na criação de outros problemas (titubeio na fixação do local de ocorrência do fato gerador, e expansão da lista de serviços para atividades que não se classificavam como tal).

No que interessa ao presente feito, o item 72 da Lista de Serviços Anexa ao Decreto-Lei n. 406/68 foi revogado e, em seu lugar, o verbete 14.05 chegou chegando com a seguinte redação:

> *14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.*

De bate pronto, percebe-se que o legislador complementar, além de incluir o serviço de restauração entre aqueles sujeitos à tributação do ISS, suprimiu a ressalva que constava no tipo legal anterior, aparentemente estabelecendo a sua incidência em toda e qualquer atividade lá descrita, independentemente das circunstâncias que gravitassem ao redor da sua respectiva prestação.

Tempos depois, em 29/12/2016, meio que como uma prova de que a LC 116/2003 não cumprira todas as expectativas que dela se esperava, foi publicada a Lei Complementar n. 157/2016, que, entre seus vários dispositivos, alterou novamente a redação do subitem 14.05, que passou a ser lido assim:

> *14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, **beneficiamento**, **lavagem**, **secagem**, **tingimento**, galvanoplastia, anodização, **corte**, recorte, plastificação, **costura, acabamento**, polimento e congêneres de objetos quaisquer.*

Como se vê, essa última versão agregou aos serviços tributáveis via ISS os ofícios de costura e acabamento, e manteve a supressão da ressalva dessa mesma incidência nos casos de industrialização ou comercialização.

A não reprodução expressa dessa exceção no item 14.05 da lista da LC 116/2003, na redação dada pela LC 157/2016, resulta em pelos menos duas interpretações constitucionais sobre os limites entre as competências do ISS e do ICMS.

A primeira delas é a meramente literal, segundo a qual basta a realização das atividades de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento para que haja a incidência do ISS, independentemente do tipo de obrigação, da finalidade e da destinação do serviço.

Contudo, não obstante as diversas alterações legislativas do ISS, é incontroverso que todas elas ocorreram no plano infraconstitucional. No patamar de cima, naquele que vale, a essência do ISS – e também do ICMS –, permaneceu a mesma por todo esse tempo, o que leva à segunda interpretação do motivo da supressão da ressalva no item 14.05: do ponto de vista constitucional, ela era desnecessária, já que seu espírito deflui do própria natureza de ambos os impostos. Em outras palavras, a lei não precisa avisar – *porque a Constituição já o faz* – que os serviços são absorvidos pelo ciclo produtivo em que estão inseridos, e que, por isso mesmo, estas atividades sofrem a incidência do ICMS e não do ISS.

Esta segunda interpretação, muito mais abrangente, coerente, sistêmica, técnica, e correta, leva em conta o princípio constitucional do pacto federativo e da divisão das competências tributárias. Como se sabe, a Constituição Federal, antes de tudo, é uma carta de atribuições a cada uma das pessoas jurídicas de direito público. No campo tributário, essa distribuição de funções se manifesta na faculdade que a União, os Estados e os Municípios têm para instituir, nas suas legislações internas, os tributos a eles reservados.

É esta divisão rigorosamente demarcada de competências tributárias, que evita a ocorrência da bitributação, entendida como a impossibilidade de dupla incidência sobre o mesmo fato gerador. Trazendo este preceito para o caso presente, é ela que permite que União Federal (competente para criar o IPI), os Estados (titular do ICMS), e os Municípios (porta-voz do ISS) dividam a arrecadação dos impostos incidentes sobre diferentes etapas do processo de fabricação têxtil, sem, com isso, invadirem o latifúndio um do outro.

Basicamente, a solução para os aparentes conflitos de competência entre ISS e ICMS que surgem no setor têxtil pela própria natureza das operações, se dá pela separação conceitual da obrigação de fazer (sobre as quais incide o ISS) e dar (tributáveis via ICMS). Por ser bastante didática, esta segregação parece ter saído de uma aula preparatória para o exame de OAB. Os novos bacharéis em direito, ainda sedentos por regras de fácil assimilação, e ansiosos pela aprovação no concurso que chancelará seu acesso à profissão, mal imaginam, mas essa equação não foi inventada por um esperto professor de cursinho, mas sim pela própria Constituição Federal.

Para quem duvida da origem constitucional da regrinha, sugere-se a leitura dos artigos 155, II e 156, III do Texto Magno:

> *Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:*
> *II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;*
>
> *Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:*
> *III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.*

De acordo com a Constituição Federal (que está acima do professor de cursinho), as competências tributárias dos Estados e dos Municípios estão divididas do seguinte modo: o ISS incide sobre o esforço humano, isto é, sobre as obrigações de fazer (exceto sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação); já o ICMS incide sobre a transferência de bens.

A esse respeito, a própria Suprema Corte já se posicionou no sentido de que o ISS só incide sobre obrigações de fazer, ao afastá-lo sobre a locação de bens móveis. Veja-se:

> *TRIBUTO – FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da Carta Federal é conducente a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela previstos. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO. A terminologia constitucional do Imposto sobre Serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que imponha o tributo considerado contrato de locação de bem móvel. Em Direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir a locação de serviços com a de móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são de observância inafastável - artigo 110 do Código Tributário Nacional (RE 116.121/SP – Julgado em 11/10/2010 – Rel. Marco Aurélio).*

Do extenso e histórico acórdão, extrai-se as seguintes passagens que confirmam a adoção dos conceitos de "dar" e "fazer" por esta E. Corte de Justiça:

> *"(...) Em síntese, há de prevalecer a definição de cada instituto, e somente a prestação de serviços, envolvido na via direta o esforço humano, é fato gerador do tributo em comento". (Min. Marco Aurélio, p. 4 do voto).*
>
> *"(...) o ISS somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da locação de bens móveis. (Min. Celso de Mello, p. 3 do voto)*

Noutra oportunidade, ao analisar a incidência do ISS sobre os serviços de arrendamento mercantil, esta E. Casa de Justiça também adotou a mesma premissa para manter a cobrança do tributo. Veja-se:

> *"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O arrendamento mercantil compreende três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o chamado lease-back. No primeiro caso há locação, nos outros dois, serviço. A lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III do artigo*

> *156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição.* ***No arrendamento mercantil (leasing financeiro), contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar****. E financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do lease-back. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 592.905/SC – Julgado em 02/12/2009 – Rel. Min. Eros Grau).”*

Esta separação entre “dar” e “fazer” já não é tão simples assim nas operações híbridas, nas quais a prestação de serviços e a circulação de mercadoria surgem misturadas. E de novo, mesmo que o professor de cursinho não tenha avisado, a solução para estes aparentes conflitos se dá pela Constituição Federal: se por trás do núcleo do negócio jurídico em que atividade está inserida, há uma obrigação de "fazer", haverá incidência do ISS; se houver uma obrigação de dar, de entregar uma coisa, a incidência será do ICMS.

Neste sentido, veja-se o julgamento da ADI nº 4413, de autoria da Confederação Nacional da Indústria, e da ADI nº 4389, movida pela Associação Brasileira de Embalagem, nas quais foi postulada a interpretação conforme a Constituição do subitem 13.05 da Lista de Serviços anexa à LC 116/2003, antes da alteração trazida pela LC 157/2016, verbete este que tratava da incidência do ISS sobre o fornecimento de embalagens por encomenda, reconhecidamente uma operação mista. Na época, a liminar foi concedida nos seguintes termos:

> *CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa,* ***para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria.*** *Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS (o destaque não é do original).*

Não só a jurisprudência deste E. STF considera o contexto em que o serviço é prestado, mas também a própria legislação. A mesma LC 157/2016 serve como prova dos nove. Se ela alterou a redação do item 14.05 da Lista de Serviços, foi ela que também modificou o item 13.05, todo ele voltado para as atividades gráficas, cuja operações são naturalmente hibridas. No novo tipo legal, o legislador afasta expressamente a incidência do ISS nos serviços gráficos, quando destinados a posterior comercialização ou industrialização. Veja-se:

> *13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia,* ***exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação,*** *tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.*

Logo, à luz dos julgados acima reproduzidos, e do item 13.05 da Lista de Serviços, conclui-se que o trabalho humano que interessa ao ISS deve ser o centro da relação jurídica contratada. O "fazer" deve ser, pois, o principal elemento do negócio jurídico, ainda que, depois disso e, secundariamente, haja entrega de algum bem.

De outro lado, na circulação de mercadorias que interessa ao ICMS, o centro da relação jurídica deve ser ocupado pela transmissão da titularidade de um bem. Nessa hipótese, a entrega da coisa e o pagamento do preço são as principais obrigações a serem cumpridas pelos contratantes, ainda que, antes disso e *em caráter instrumental*, haja diversas obrigações de fazer que culminem com a produção e com a comercialização da mercadoria.

Em vista destas considerações, tem-se que há atividades de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, que, de fato, devem ser tributadas pelo ISS. Isso sempre ocorrerá quando a prestação de serviço for o núcleo do negócio jurídico, ou, noutro dizer, quando a obrigação de fazer e o bem daí derivado não se destinarem à produção industrial ou à comercialização. Em termos mais diretos: quando o próprio tomador for o usuário final. Nestas hipóteses, o ISS incidirá sobre as atividades de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, tudo em perfeita harmonia com o art. 156, inc. III, da Constituição Federal.

Por outro lado, a atividade exercida pela indústria têxtil e de confecções da qual resultem bens que servirão de insumo, produtos intermediários ou materiais de embalagem ao ciclo econômico de outras mercadorias, deve ser tributada pelo ICMS, na forma do art. 155, inc. II da Constituição Federal.

A incidência do ICMS nestes casos não ocorre por uma teoria da conspiração urdida contra o ISS, com se ele fosse uma espécie patinho feio dos impostos. Não é questão de preferência de um em relação ao outro. No direito tributário, as respostas não surgem por meras afinidades eletivas, mas sim pelo que é ditado pela Constituição Federal e pela natureza dos institutos.

Vem daí que, pela letra da Constituição, e excetuando-se os serviços de transportes interestadual e intermunicipal que não interessam ao caso aqui tratado, o ICMS sempre vai pressupor e onerar o ciclo econômico de uma determinada mercadoria, dela extraindo a riqueza dos seus integrantes na exata medida das respectivas capacidades contributivas. É exatamente por isso que as várias e sequenciais transferências de titularidade de bens (e dos respectivos beneficiamentos aplicados sobre os mesmos), que desaguam na venda de um produto acabado ao consumidor final, atrai a competência tributária estadual e repele as demais, incluindo-se aqui o ISS, sem com isso haver qualquer violação ao art. 156, inc. III da CF.

Reitere-se, portanto, o que se disse mais acima: a incidência do ISS ou do ICMS nas operações mistas, que envolvam prestação de serviço com fornecimento de mercadorias, não é dada pela simples verificação de um "fazer" e de um "dar". É preciso ir além e encontrar o núcleo da relação jurídica. Dito isso, e aproveitando o bordão do ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho, a regra é clara: haverá a incidência do ICMS quando as atividades de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, forem desenvolvidas para produzir bens a serem inseridos no ciclo econômico de outra mercadoria. Por outro lado, haverá a tributação do ISS se estes mesmos serviços forem prestados fora de qualquer contexto produtivo, normalmente encomendados diretamente pelo próprio tomador.

E é assim que as coisas são, porque as atividades de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, no contexto do ciclo econômico do segmento, não se configuram como prestações de serviço autônomas, mas sim como partes integrantes das várias fases do processo de industrialização e comercialização das peças depois de efetivamente acabadas, atraindo, por isso, a incidência do imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS).

Exemplificando para facilitar: se uma pessoa fosse contratada para imprimir numa camisa em branco determinados dizeres solicitados diretamente pelo encomendante, algo como "SOBRE ESTA PEÇA HAVERÁ A INCIDÊNCIA DO ISS", aí sim haveria a sujeição do imposto municipal. E é assim não porque a camisa contém essa afirmação, mas porque, neste caso, o serviço, como autêntica obrigação de fazer, está assumindo o protagonismo da relação negocial.

Porém, aproveitando o mesmo exemplo, se uma pessoa recebesse um pano branco, sobre ele somente imprime os dizeres "SOBRE ESTA PEÇA HAVERÁ A INCIDÊNCIA DO ICMS", e, em seguida, o devolve a um industrial, que nele promoverá outras modificações na sua natureza, a operação sujeitar-se-ia ao imposto estadual. E é assim não porque o pano contém essa afirmação, mas sim porque, neste caso, a atividade têxtil representa apenas uma das etapas das confecção, todas elas voltadas para a fabricação de algo novo, diferente, talvez o distintivo de uma camisa, ou emblema de uma bandeira, ou quem sabe o detalhe de uma malha, e que são absorvidas pela onda do ciclo produtivo, que atrai a incidência do ICMS e afasta a do ISS.

Por isso, pretender alcançar pelo ISS uma atividade-meio que, por definição, não tem autonomia, é querer tributar algo sem vida própria, que, não existe separadamente do objeto a que se vincula (peças cortadas, recortadas, costuradas e acabadas), este sim o núcleo da contratação. Isso causa arrepios à competência tributária prevista no art. 156, III, da CF e, excedendo a competência municipal, acaba por ofender a competência tributária estadual (art. 155, II, da CF).

Nessa perspectiva, os serviços de acabamento (tais como estamparia, transfer, cilindro digital, tingimento, lavanderia, alvejamento, desengomagem, purga, desmineralização, mercerização, chamuscagem, ramagem, feltragem, dublagem, flocagem, calandragem, recoberto) e costura (beneficiamento, peça confeccionada, estamparia, silk-screen, tingimento, lavanderia, amaciamento, stone-wash, destruído, desbotado, sobretinto, lixado, jateado, pincelado, bordado), por exemplo, ***quando inseridos no âmbito de um ciclo econômico,*** não estão sujeitos ao ISS, mas sim ao ICMS.

A conclusão contrária implica em três flagrantes inconstitucionalidades: violação ao princípio da não-cumulatividade, da divisão das competências tributárias e da isonomia.

Vejamos.

Como se sabe, o ICMS "será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores" (art. 155, § 2°, inc. I, CF/88). Logo, a incidência do ISS sobre as atividades de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, das quais resultem produtos destinados a agregar o ciclo produtivo, viola a regra acima e faz com que a incidência tributária ao longo da respectiva cadeia mercantil seja, do ponto de vista fiscal, em cascata, e do ponto de vista econômico, mais onerosa aos contribuintes envolvidos na operação. Obviamente este modelo é inconstitucional, haja vista a estrutura constitucional do ICMS de imposto não-cumulativo sobre o consumo, a ser suportado pelo consumidor, de forma destacada.

Além de ofender à não-cumulatividade, a incidência do ISS implica em manifesto esbulho da competência tributária estadual por parte dos Municípios. Por tudo o que já foi destacado acima, as zonas limítrofes de incidência do ICMS e do ISS, embora quase tangenciem entre si, estão bem delimitadas: aos Estados, foi atribuída a competência para tributar operações de circulação de mercadoria; aos Municípios, reservou-se a competência para arrecadar impostos sobre a prestação de serviços. Nos casos de intersecção entre ambos os campos de atuação, em que a situação se aproxima de uma bitributação, a solução é dada pela identificação do núcleo do negócio jurídico em que a atividade está inserida.

É dizer que se os serviços de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, integram um processo produtivo, o esforço humano é absorvido pela cadeia mercantil, e a operação será tributada via ICMS. A pretensão dos Municípios de cobrarem o ISS mesmo nos casos em que eles façam parte de um ciclo econômico maior, se constitui, portanto, em evidente invasão da competência tributária exclusiva dos Estados.

Por último, a incidência do ISS gera uma desigualdade entre contribuintes em situações análogas. Isso porque, quando admitida a tributação da operação pelo ICMS, a confecção de mercadorias para inserção do ciclo econômico do produto final será tributada de uma forma quando praticada por terceiros e de outra forma quando praticada como atividade meio pela própria empresa (indústria).

A Constituição proíbe que pessoas que se encontram em situação equivalente sejam tributadas de modo diferente. É precisamente isso que ocorre quando a mesma atividade de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, que produz bens destinados a operação de comercialização ou industrialização, está sujeita a diferentes tratamentos tributários apenas em função de quem a exerce.

Vale dizer: ao se admitir a pretensão dos Municípios, se os serviços fossem terceirizados pela indústria têxtil, eles seriam tributados via ISS. Por outro lado, se estes mesmos serviços fossem assumidos pela própria empresa produtora da mercadoria final, haveria a incidência do ICMS, e os créditos decorrentes dessas operações seriam mantidos e compensados na operação seguinte. Haveria, com isso, um problema de desigualdade porque a mesma atividade seria tributada de maneira diferente, sem uma justificativa razoável para a diferenciação. Tal situação é vedada pela Constituição, pois não pode a mesma atividade receber tratamento jurídico diferenciado para fins tributários sem que haja uma finalidade legítima a ser alcançada e uma medida de comparação congruente com esse objetivo.

Para se evitar a concretização destas inconstitucionalidades, a Autora requer que se interprete o item 14.05 da Lista de Serviços anexa à LC 116/2003, na redação dada pela LC 157/2016, conforme à Constituição Federal, declarando-se, em sede de controle concentrado das normas, mas sem supressão de texto, que:

(i) haverá a incidência do ICMS quando as atividades de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, estiverem inseridas no ciclo econômico de outra mercadoria; e

(ii) haverá a tributação do ISS se estes mesmos serviços forem prestados sob a forma de encomenda do tomador.

IV – DA MEDIDA CAUTELAR

A concessão de medida cautelar, em sede de controle normativo abstrato, pressupõe a concomitância dos requisitos concernentes ao *fumus boni iuris* e ao *periculum in mora*, ambos presentes no caso em apreço. Exige-se, além deles, a presença de outras duas condições consideradas essenciais pelo Supremo Tribunal Federal: a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes do ato impugnado e a necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão.

O *fumus boni iuris* resta configurado pela própria demonstração de que uma das possíveis interpretações sobre os serviços de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, previsto no subitem 14.05 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, na redação dada pela LC 157/2016, contraria a Constituição Federal, ao violar, flagrantemente, as regras de competência tributária, o caráter não-cumulativo do ICMS e as exigências igualdade e neutralidade tributárias.

Como fundamento dessa interpretação está a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o imposto sobre serviço só pode incidir sobre relações jurídicas cujo núcleo seja uma obrigação de fazer, jamais uma obrigação de fornecer bens. Nesse sentido, o exame dessa jurisprudência permite concluir que aquelas relações nas quais prepondere o fornecimento de bens destinados a posterior comercialização ou industrialização não podem conduzir à cobrança de ISS, mas, unicamente, de ICMS.

Afigura-se também evidente o prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (*periculum in mora*), em face das conseqüências advindas da manutenção da dupla exigência tributária sobre o mesmo fato, agravada substancialmente pela imposição de penalidades, pela cobrança de juros e pela dificuldade de restituição do indébito tributário, após a edição da Lei Complementar nº 157/2016.

A LC 157/2016, incluiu no subitem 14.05 da Lista de Serviços as atividades de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, e, desde então, os Municípios têm aplicado a interpretação literal ao dispositivo, restando evidente a presença do *periculum in mora*.

A pendência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência de ISS sobre as atividades de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, de que resultem bens que se agregam à cadeia produtiva ou comercial, focará as empresas a ajuizar demandas individuais para afastar a aplicação do subitem em comento e, depois de resolvida a controvérsia, ainda deverão pleitear a restituição dos valores indevidamente pagos.

Além disso, a incerteza igualmente enseja o ajuizamento de execuções fiscais quanto ao tributo não recolhido, mas que o Ente Federado entende devido, com a incidência de juros e de multa. Todas essas demandas judiciais, que possivelmente terão resultados divergentes, gerando insegurança jurídica, seriam evitadas com a concessão da medida cautelar pleiteada. Ora, nesse contexto, ficam evidentes os danos emergentes da manutenção da interpretação inconstitucional do ato impugnado e os prejuízos advindos da demora da decisão definitiva da presente ação direta.

Da mesma forma, a concessão da medida cautelar é essencial para unificar o procedimento adotado pelas empresas e a tributação incidente sobre elas. Quando uma empresa recolhe ISS ao exercer determinada atividade e outra empresa recolhe ICMS ao desenvolver a mesma atividade há um grave problema de igualdade, que acarreta desequilíbrios na concorrência no âmbito do setor. Também por isso é imprescindível e urgente o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal quanto ao objeto da presente ação direta.

IV – DO PEDIDO

Em face do que foi exposto, a Autora requer:

(i) A concessão da medida cautelar pleiteada, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/99, com a determinação de que, até o julgamento definitivo da presente ação, os serviços de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento constantes do subitem 14.05 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/03, com redação dada

pela LC 157/2016, inseridos no ciclo econômico da produção de outros bens antes de alcançar o usuário final, ou seja, quando forem insumos para a produção bens que serão utilizados em operações comerciais ou industriais posteriores, sejam interpretados conforme à Constituição, para que não incida ISS sobre eles;

(ii) a solicitação de informações aos Excelentíssimos Senhores Presidentes da República e do Congresso Nacional (art. 6° da Lei n. 9.868/99); a citação do Advogado-Geral da União (art. 103, § 3°, da Constituição) e do Procurador-Geral da República para apresentarem manifestação no prazo de quinze dias (art. 8° da Lei n. 9.868/99);

(iii) A procedência do pedido para interpretar os serviços de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento constantes do subitem 14.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/03, com redação dada pela LC 157/2016, conforme os artigos 155, inc. II e 156, inc. III, ambos da Constituição, declarando-se a inconstitucionalidade da interpretação que faça incidir o ISS quando tais serviços estejam inserido no ciclo econômico da produção de outros bens antes de alcançar o usuário final, ou seja, quando utilizados como insumo ou produto intermediário em operações comerciais ou industriais.

Protesta, desde logo, pela juntada dos documentos anexados e pela realização de sustentação oral na sessão de julgamento, o que faz com fundamento no art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, requerendo a intimação dos subscritores da presente para tal finalidade.

Por fim, requer que todas as intimações referentes a este processo sejam realizadas em nome do **Dr. Helcio Honda**, inscrito na **OAB/SP 90.389**, com escritório na **Av. Paulista, 475, 3º andar, CEP 01311-908, São Paulo/SP – Tel.: (11) 2149.0500**.

Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo – Brasília, 05 de junho de 2018.

HELCIO HONDA
OAB/SP 90.389